

1500546-12.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... e demonstração das provas do tráfico em sua residência, que aconteciam diuturnamente, debaixo do seu nariz, com o seu amplo consentimento, já que é de conhecimento, tanto da Polícia como do Judiciário que o réu faz de sua residência um ponto de tráfico de drogas, onde já foi preso por três vezes, todas em flagrante delito, tamanha é a certeza da impunidade que impera nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500546-12.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-12.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENNER GUSTAVO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DENNER GUSTAVO DA SILVA (vulgo "Dedê"), qualificado às fls. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia:

"Consta do incluso auto de prisão em flagrante que no dia 30 de junho de 2022, por volta das 07h30min, na Avenida Osvaldo da Silva, nº 430, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado guardava e tinha em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em: (i) 03 (três) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,39 (trinta e nove centigramas - lacre nº 0027041); (ii) 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 2,64g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas - lacre nº 0027042) e (iii) 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total aproximado de

8,03g (oito gramas e três centigramas - lacre nº 0027403), conforme boletim de ocorrência de fls. 09/13, mandado de busca e apreensão de fls. 14/15, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, fotografias de fls. 19/21, laudo de constatação provisório de fls. 23/25 e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 99/101. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de drogas acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a guardá-las e mantê-las em depósito em sua residência, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1502913-21.2022.8.26.0482, no dia dos fatos, policiais civis ingressaram na casa do imputado, onde foram recebidos por sua avó, a fim de averiguarem informes e campanhas prévias que indicavam a ocorrência de tráfico de substâncias entorpecentes no local. O denunciado, que dormia no quarto dos fundos da casa no momento da diligência, negou ter drogas no local e possuía uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais). No primeiro quarto da casa, onde o denunciado dorme com a sua companheira, os agentes públicos localizaram, no bolso de um short do imputado 03 (três) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,39 (lacre nº 0027041), embaladas separadamente, em sacos plásticos. No quarto onde o denunciado dormia com a sua irmã adolescente, foi localizada uma faca de cabo preto contendo resquícios de droga; no quarto ao lado deste, foram encontradas balanças de precisão, escondidas em meio a roupas, com resquícios de droga; na cozinha, havia saquinhos plásticos de "geladinho" dentro de um liquidificador. Na parte externa da casa foram localizadas: 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 2,64g (lacre nº 0027042), embalada em saco transparente, a qual estava escondida em buracos no muro do corredor direito da casa; no corredor esquerdo havia, escondida em tijolos, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido total aproximado de 8,03g (lacre nº 0027403), embalada em saco plástico azul; aos fundos do quintal havia, dentro de uma sapateira, uma faca de cabo vermelho com resquícios de substância entorpecente. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, a confirmar as informações prévias sobre a traficância de drogas pelo denunciado em sua casa, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 160/163), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 166), o despacho de fls. 169/173, de 6 de setembro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 210/211), pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 210/211), pugnou pela absolvição do réu por ausência de provas da prática delitiva, ou alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Subsidiariamente, requer seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime aberto e substituída por restritiva de direitos, rechaçando o pedido do Ministério Público para exasperação da pena pela reincidência, já que não há transito em julgado em definitivo.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar de fls. 14/15; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; pelas fotografias

de fls. 19/21; laudo de constatação preliminar de fls. 23/25; pelo laudo químico toxicológico de fls. 99/101, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0027041 ) Descrição: 3 (três) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido petrificado bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 1,72 grama(s) - um grama e setenta e dois centigramas. Massa Líquida: 0,39 grama(s) - trinta e nove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0027403 ) Descrição: 1 (uma) porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Acompanha 1 (um) invólucro(s) plástico(s) azul. Massa Bruta e/ou Quantidade: 10,47 grama(s) - dez gramas e quarenta e sete centigramas. Massa Líquida: 8,03 grama(s) - oito gramas e três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0027042 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de material sólido petrificado bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 4,74 grama(s) - quatro gramas e setenta e quatro centigramas. Massa Líquida: 2,64 grama(s) - dois gramas e sessenta e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial em aparelho celular de fls. 130/154; pelas cópias do Disque Denúncia e do Relatório de Investigações Policiais de fls. 4/10 (APENSO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - P. 1502913-21.2022.8.26.0482) além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Eva Garcia da Silva, declarou que é avó de Denner, presta depoimento sem compromisso legal, apenas como informante. Sobre os fatos narrou que não viu nada do que é imputado ao Denner que estava em sua casa, não viu, não pode falar nada. Disse que nunca viu seu neto vender droga em sua casa, e não gosta que faz coisa errada. Ele trabalha ajudando seu genro como azulejista para sustentar seu filho, e tem vez que é quase a semana inteira, mas só quando seu genro falar que não precisa ir, senão ele vai quase a semana toda. Disse que a balança, grande, que comprou para poder pesar massa de pão, massa de pastel, e não viu que eles tinham pegado, senão tinha falado. Que comprou a balança. Os saquinhos plásticos foi sua neta que comprou para fazer geladinho, deixava dentro do armário da cozinha. Afirma que apreenderam os celulares de suas netas, também apreendeu o celular do Denner, mas não sabe a marca, o da sua neta é Xiami, e da pequena de 8 anos, acredita que seja Samsung.

A testemunha André Luiz Zanandrea, Investigador de Polícia, declarou, sob o crivo do contraditório que Denner já é conhecido na Delegacia de Entorpecentes pois já foi preso várias vezes pela polícia, nos últimos dois anos, em 2020 e 2021 e agora em 2022, e todas as vezes que era preso, também era apreendido crack, saquinho de geladinho, balança, faca, sempre o mesmo modus operandi. Fez uma observação em setembro de 2021 quando conseguiram realizar o flagrante. Quando chegou essa nova denúncia, de pronto já sabendo como ele age, foi até a residência dele, montando um ponto de observação, pode ver a movimentação de venda de entorpecentes pelo portão, pois era de ferro fechado. Como era período noturno, apenas via, não conseguiu fazer imagens, por ser sempre em período noturno. A autoridade Policial solicitou mandado de busca e na residência, no dia 30 de junho, no local, viram o portão aberto, todos dormindo e Denner estava com a avó e algumas menores de idade, como a namorada e irmãs. Denner estava no quarto do fundo, e com ele foi apreendido R\$ 10,00 no bolso da bermuda, e na casa, no quarto anterior ao qual ele estava com uma moça, que posteriormente foi identificada como sendo sua irmã, foi localizado duas balança de precisão com resquícios de drogas em meio as roupas. No quarto da frente, onde ele utiliza com a esposa e uma criança pequena, foi vistoriado e em uma gaveta da cômoda, encontraram um short, que Denner confirmou que era dele, e no

bolso, 3 porções de crack embalados em saquinhos de geladinho em pequena fileira. Continuou as buscas ao lado externo da casa, localizou um velho sofá na lateral da casa, e embaixo dele, junto com tijolos que sustentava o sofá, encontrou uma porção, embalada em saco plástico azul, e ao abrir constatou que era maconha. No corredor que leva aos fundos da casa, em um buraco no tijolo, daqueles de 6 furtos, encontrou diversos fragmentos de crack embalados em saquinhos plásticos transparente, típicos de geladinhos, e no fundo da casa, outra faca com resquílios de entorpecentes. Na cozinha, ao final das buscas, dentro do pote plástico do liquidificador com diversos saquinhos plásticos de geladinho, sem uso. Diante dos fatos, a Autoridade deliberou pelo flagrante delito por tráfico de drogas. Afirma que a avó do réu, d. Eva, disse que em relação aos saquinhos de geladinho, ela disse que fazia para a venda, mas naquele momento não havia nenhum no congelador. Não havia nenhuma placa na residência indicando que ali se vendia "geladinhos". A avó, sempre dizia que o neto era usuário. O quarto onde encontrou duas balanças, pelo que aparenta não era utilizado, era como se fosse uma dispensa. Na observação de campo, utilizava um carro comum, e a olho nú, a menos de cinquenta metro, pois fica numa avenida e mesmo no período noturno há um bar que fica com as luzes acesas. O que deu para perceber é que as pessoas vinham e mesmo com o portão fechado, eles iam até a lateral pegavam algo e iam embora. Não chegou a abordar nenhuma pessoa naquela local.

A testemunha Cezar Naim de Oliveira Wehbe, sob o crivo do contraditório declarou que dos fatos, o investigador Zanandrea lhe reportou que desde as primeiras captação de imagens, pediram um mandado de buscas, salvo engano, e foi preso na primeira oportunidade, e depois vinham outras novas denúncias, tendo o Zanandrea, com o mandado de prisão, na residência do Denner, foi o primeiro a aborda-lo, ele estava com uma moça, e a esposa com a criança num primeiro quarto, nesse quarto, dentro do bolso de um short, uma porção de crack, salvo engano, apresentando para o Policial Zanandrea. No restante das buscas, foi encontrada balança de precisão em outro quarto, ou seja, tinha objetos e drogas espalhados por toda a casa. tinha droga na parte externa, não se recorda se no corredor, que Zanandrea encontrou, tinha droga escondida num short na frente, e balança de precisão, salvo engano, eras duas, num outro quarto, espalhado pela residência. Ao final, Zanandrea conversou com o réu, disse a princípio que não tinha droga, mas acabou confessando que tinha. Dentro de um liquidificador havia saquinhos de geladinho que são utilizados para embalar o crack e diante disso foi lavrado o flagrante. Uma balança foi encontrada num quarto onde deveria estar a irmã, mas essa dormia com ele no quarto do fundo e a esposa no quarto da frente. Em relação à campana realizada por Zanandrea, houve duas ou três ocorrências, não se recorda, e ele fez observações, inclusive na última, mas em relação a captação da imagens, ele fez na vez anterior. Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à

palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278). Em seu interrogatório, o réu Denner Gustavo da Silva, declarou que já cumpriu pena de prisão e respondeu a outro processo anteriormente. Que quanto aos fatos disse que é verdade, que as drogas eram para o seu uso. As porções encontradas em seu short, os três papéis, não tinha costume de deixar no short. Deixou uma porção no tijolo fora da residência para fumar no dia seguinte e as facas, as utiliza para raspar o cachimbo para tirar a borra. Uma das balanças era da sua avó, que ela vendia pão e pastel, e a outro não faz ideia de quem é, não sabe como apareceu lá. A balança que tinha resquícios de drogas, foi a que apareceu em sua casa. Embora não admita que faz comércio de drogas em sua residência, está situação foi afirmada e confirmada pelas demais provas, principalmente pela robusta prova oral amealhada aos autos.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Esta não é a primeira oportunidade em que a Polícia localiza drogas em sua residência, e é de fato que desde a tenra idade se dedica ao tráfico de drogas, especialmente pelas denúncias trazidas e que foram substanciais para emissão de mandado de busca e apreensão na residência que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, saquinhos para embalar a droga, facas com resquícios de drogas, escondidas em vários lugares da residência, inclusive do lado de fora, de forma a despistar a atuação de eventual atuação da polícia, como a que se deu no local dos fatos.

Quanto a alegação da avó, não há como acolhe-la, pois embora o réu também informe a atividade da avó, não há qualquer prova da sua realização, até porque, tanto na faca como na balança de precisão foi detectada a presença de cocaína, base para o crack, que o réu diz que utilizava para tirar a borra do cachimbo, ademais, esse objeto sequer foi encontrado e apreendido.

Quanto ao celular apreendido que a avó Eva, informou pertencer a sua neta de apenas 11 anos, sem citar nem o nome da menina, foi encontrado grande quantidade fotos de drogas, pessoas fazendo uso de drogas e conversas que denotam o mercado espúrio que seu neto, o réu Denner, pratica naquela residência, aos olhos da própria avó e das menores de idade, sua irmã e companheira que com ele convivem, demonstrando sua total desfaçatez ao tentar proteger a vida delinquente que o neto vive, inclusive, é de se notar a corrupção dos menores, corroendo a moralidade e ética deles naquela residência, em tão tenra idade, embora esse crime não foi objeto destes autos.

D. Eva ainda faz de tudo e usa o seio familiar para encobrir e tentar livrar os netos da grave acusação que pesa contra Denner. Disse que não viu nada, não sabe de nada, que o neto trabalha com o genro que é azulejista, que as vezes vai a semana toda e outras alguns dias, apenas. Embora a quantidade de droga não seja tão expressiva, disse que seu neto é usuário, na maior naturalidade, encobrendo sua atividade espúria, tudo para tentar desviar o foco da investigação e do levantamento e demonstração das provas do tráfico em sua residência, que aconteciam diuturnamente, debaixo do seu nariz, com o seu amplo consentimento, já que é de conhecimento, tanto da Polícia como do Judiciário que o réu faz de sua residência um ponto de tráfico de drogas, onde já foi preso por três vezes, todas em flagrante delito, tamanha é a certeza da impunidade que impera nos dias atuais, já que, como dito, é a terceira vez que é preso em flagrante pelo mesmo, grave crime de tráfico de drogas na residência.

Percebe-se que Eva disse que tem a balança de precisão para pesar massa de pão e

pastel que faz para vender, mas não sabia que eles tinham pego, ou seja, mente o tempo todo, principalmente tentando fazer parecer que realmente faz tais alimentos para venda, mas na verdade, são objetos utilizados, evidentemente, para pesar drogas.

Vêm a corroborar com a prova colhida nos autos, denúncia anônima anexada aos autos apensados nº 1502913-21.2022.8.26.0482, de folhas 5/7 informando que "tráfico ocorre no local, há movimentação muito grande usuários entrando e saindo do imóvel e o consumo ocorre no interior da residência. movimentações ocorrem diariamente, a partir das 20 horas". A par de tal denúncia, houve a preparação dos policiais da DISE local que fizeram campana e observação de campo, tirando fotos e fazendo levantamento do local (fls. 8/10), que culminou com expedição de Mandado de Busca Domiciliar que apreendeu as drogas e os objetos na residência, confirmando as denúncias recebidas.

Denota-se in casu, que a notícia-crime, em si, reflete a indignação da população acerca da traficância realizada pelo acusado, fato este que ficou demonstrado com a apreensão das drogas.

Nesse sentido:

"Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de suma importância para a repressão ao crime. Tanto é que foram criados diversos "disque-denúncias". Tendo a Polícia Judiciária o dever de apurar as infrações penais que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações anônimas." (TJSP -Apelação nº 0064980-49.2013.8.26.0050. Rel. Paulo Rossi, j. em 19.02.2014)

Obtempere-se que no caso trazido à liça, o acusado foi surpreendido pelos policiais no momento da prática delitiva, o que constitui, desta forma, a evidência do fato punível, a certeza visual do crime.

Neste prisma, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"O réu foi preso em flagrante", que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". De acordo com Hélio Tornaghi - "prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime". Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca, é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5a ed., 11/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido: PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: 59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)" (TJSP Apelação nº 01112349.3/7-0000-000. Rel. Eugênio Augusto Clementi Júnior, j. em 05.12.2007) Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu, na Rua Osvaldo da Silva, 430, Ana Jacinta (3 porções de cocaína, na forma de crack, com peso de 0,39 g (trinta e nove centigramas) e 1 porção de maconha, com peso de 8,03g e mais 1 porção de cocaína, na forma de crack pesando 2,64 (dois gramas e sessenta e quatro centigramas) além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, uma folha de papel com anotações diversas que contem contas, dados pessoas, valores, altíssimos para quem é motorista de aplicativo, bem como a balança encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a

diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão.” (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

“ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos.” (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: “Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia no celular apreendido, conversas direcionada ao tráfico de drogas, principalmente com pessoa chamado de “Meu gato”, em que num áudio enviado pelo réu diz “Fala pra ele que amanhã eu levo as 5 aí pra ele” e “Idiota vai faze o mlk traze 5g p vc”.

Observo que o réu diz que o celular era de sua irmã, provavelmente “Layanne”, que também utiliza o aparelho, pois há no cadastro, o endereço de seu e-mail

kkjlayanne43@gmail.com e também há de d. Eva Garcia, avó do réu

evaagarcia1404@gmail.com, e portanto, evidencia com grande eloquencia nos autos a participação direta da ré no comércio espúrio de drogas, utilizando celular que disse ser de outra pessoa, certamente para despistar e dificultar a investigação.

Já a perícia no celular do réu, foi igualmente importante para demonstrar que também tinha fotos (fls. 132/139) que denotam o envolvimento com comércio ilícito de droga, com evidência para fotos onde aparece menores(adolescentes) fazendo uso de drogas, possivelmente, irmãs do acusado, contudo, não houve tal comprovação nos autos, já que evidente que elas também utilizam o celular, além de fotos de grande quantidade de droga, arma de fogo, pessoas portando arma de fogo, munição, pessoas fazendo uso de drogas, que denotam com eloquência a utilização do aparelho pelo réu.

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava em sua residência, de onde retirava parte para a venda a terceiro.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência de sua avó, D. Eva, abertamente, na frente de todos os vizinhos e familiares que moram naquela residência, que por sinal, são todos menores de idade,

sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de manter em depósito, expor a venda, vender, oferecer e guardar a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Passo a dosagem da pena.

Inicialmente, verifico que a Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão Estadual de Distribuição de Processo de fls. 41/44 e 45/46 mencionadas pelo i. Representando do Ministério Público em suas alegações finais não podem servir para exasperação da pena base, em que pese haja condenação a pena de prisão, não se tem ainda, notícias da ocorrência do trânsito em julgado definitiva da decisão, portanto, não acolho o pedido ministerial para exasperação da pena, justificando que o réu se dedica a atividade criminosa.

Pois, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054 (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que "a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena".

Nessa linha de entendimento, no julgamento do Habeas Corpus n. 151.431 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.5.2018, Segunda Turma), o Ministro Gilmar Mendes sustentou que inquéritos e ações penais em curso tampouco podem servir de fundamento para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin divergiram do relator, mas, pelo empate, a ordem foi concedida, nos termos da seguinte ementa: "Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como Maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais



em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria" (HC n. 151.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2018).

Em 27.11.2018, essa orientação foi firmada pela Segunda Turma, em julgamento unânime: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 144.309-AgrR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).

Considerado entendimento assentado pela Segunda Turma do STF no julgamento do Agravo Regimental do Habeas Corpus n. 144.309, não podem inquéritos ou ações penais em curso fundamentar o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por esses argumentos é que não acolho o pedido do Ministério Público em não conceder a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no caso dos autos, posto que o réu embora condenado, não tem na condenação o trânsito em julgado definitivo.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do

produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.:

169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

"[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]" (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º,

da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

As quantidades de drogas apreendidas em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz, embora já tenha respondido a outros dois processos por tráfico de drogas.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade técnica, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga apreendida com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa